

1501230-54.2020.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... convicção, de que o local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

8. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501230-54.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236875/2020 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 13773381 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 222/20/591 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 2236875 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALTAIR MOURA SEVERO DOS SANTOS

Vítima:

A COLETIVIDADE

Artigo da Denúncia:

*

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) ALTAIR MOURA SEVERO DOS SANTOS(fórum), e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Christiano de Munhoz Rodrigues e Reginaldo Aparecido Lasaro.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram)

colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Christiano e Reginaldo) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

ALTAIR MOURA SEVERO DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, porque, no dia 24 de setembro de 2020, às 16h, na rua Josefina Antônia Sarkis, nº 265, bairro Vila Industrial, nesta cidade e comarca, possuía um revólver calibre 38 SPL, de uso permitido, sem numeração, no interior da sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 05), fotografia (fls. 06) e laudo de exame (fls. 44/46).

Segundo se apurou, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos para “verificar uma denúncia de nota falsa”. Ao chegarem, foram atendidos pelo denunciado que, ao perceber que eram policiais, “correu em direção à residência, levando a mão à cintura e retirando um objeto, que foi atirado para a garagem”. O denunciado foi dominado e os policiais perceberam que se tratava de um revólver desmuniado, o qual foi apreendido e periciado.

Instado, o denunciado alegou que: “não sabe se a arma está apta para efetuar disparo. Nunca tentou utilizá-la. Não tem munição. Adquiriu-a fazendo “rolo/troca” com pessoa desconhecida. Pretendia revendê-la por 8 mil reais” (fls. 04).

Interrogado em juízo, o réu alegou a arma era sua e a jogou na garagem quando viu os policiais.

Com efeito, a testemunha Christiano de Munhoz, policial civil, disse “Na data de hoje, juntamente com o policial civil REGINALDO, se dirigiu ao local dos fatos para verificar uma denúncia de nota falsa. Em lá chegando, foram atendidos pelo suspeito, que ao perceber que se tratava de polícia, correu em direção à residência, levando a mão à cintura e retirando um objeto, que foi atirado para a garagem. O suspeito, identificado como sendo ALTAIR MOURA SEVERO DOS SANTOS, foi dominado e os policiais perceberam que o objeto anteriormente jogado era uma arma de fogo, que estava desmuniada. Ao abordá-lo, o depoente deu-lhe voz de prisão em flagrante, tendo o autuado sido algemado. Em seguida, ingressaram no imóvel, procedendo buscas no quarto de ALTAIR, nada de irregular sendo encontrado” (fls. 02).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. O réu não informou a origem da arma e não apresentou nenhum documento referente a arma de fogo.

No mesmo sentido, o policial Reginaldo Aparecido Lasaro que asseverou “a data de hoje, juntamente com o policial civil CHRISTIANO, se dirigiu ao local dos fatos para verificar uma denúncia de nota falsa. Em lá chegando, foram atendidos pelo suspeito, que ao perceber que se tratavam de policiais, correu em direção à residência, levando a mão à cintura e retirando um objeto, que foi atirado para a garagem. O suspeito, identificado como sendo ALTAIR MOURA SEVERO DOS SANTOS, foi dominado e os policiais perceberam que o objeto anteriormente jogado era uma arma de fogo, que estava desmuniada. Ao abordá-lo, o policial CHRISTIANO deu-lhe voz de prisão em flagrante, tendo o autuado sido algemado. Em seguida, realizaram buscas no imóvel, indo ao quarto de ALTAIR, nada de irregular sendo encontrado” (fls. 03).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. No local apreenderam apenas a arma de fogo na posse do réu.

Perante a autoridade policial, o réu alegou “Com relação à arma de fogo ora apreendida pretendia revender como relíquia. Não sabe se a arma está apta para

efetuar disparo. Nunca tentou utilizá-la. Não tem munição. Adquiriu-a fazendo "rolo/troca" com pessoa desconhecida. Pretendia revendê-la por 8 mil reais." (fls. 04).

Diante de todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu é o autor do delito imputado.

A narrativa dos policiais foi firme e uníssona em confirmar que se dirigiram ao local para apurar denúncia de "nota falsa", sendo que ao chegarem ao local, avistaram o momento em que o réu retirou a arma de fogo que trazia à cintura e a dispensou ao solo.

Assim, não há dúvidas de que a arma de fogo estava na posse do réu, que tentou se livrar de eventual responsabilização ao dispensá-la. Tal fato, inclusive restou demonstrado na alegação do réu que admitiu que a arma lhe pertencia, muito embora tenha tentado fazer crer que não sabia que ela estava apta a efetuar disparos. Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso Salienta-se que o laudo pericial a fls. 44 concluiu que a arma de fogo era apta a efetuar disparos.

Destarte, diante do conjunto probatório, imperiosa a condenação dos réus pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena pode ser fixada no mínimo legal, pois ausentes circunstâncias judiciais negativas.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. A alegação do réu não deve ser levada a efeito para atenuação da pena. Primeiro porque ele negou circunstância essencial para caracterização do crime, ou seja, que tinha ciência de que a arma de fogo era apta. Segundo, porque, em nada auxiliou no deslinde da ação penal, a qual encontra suporte nas palavras dos policiais e apreensão em flagrante do artefato. Por fim, em caso de reconhecimento, a atenuação não poderá levar a pena aquém do mínimo legal.

Ausentes causas de aumento e diminuição.

O regime inicial aberto é suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Presentes os requisitos, cabível substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos sobreditos termos.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Altair Moura Severo dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Segundo a denúncia (fls. 53-54), no dia 24 de setembro de 2020, às 16h, na rua Josefina Antônia Sarkis, nº 265, bairro Vila Industrial, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Altair possuía um revólver calibre 38 SPL, de uso permitido, sem numeração, no interior da sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05, fotografia a fls. 06 e laudo de exame a fls. 44/46).

Ainda de acordo com a inicial, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos para "verificar uma denúncia de nota falsa". Ao chegarem, foram atendidos pelo réu que, ao perceber que eram policiais, "correu em direção à residência, levando a mão à cintura e retirando um objeto, que foi atirado para a garagem". O réu foi

dominado e os policiais perceberam que se tratava de um revólver desmuniado, o qual foi apreendido e periciado.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu disse que “pretendia revender como relíquia. Não sabe se a arma está apta para efetuar disparo. Nunca tentou utilizá-la. Não tem munição. Adquiriu-a fazendo 'rolo/troca' com pessoa desconhecida. Pretendia revendê-la por 8 mil reais” (fls. 4).

Em solo policial, Christiano de Munhoz Rodrigues, policial civil, narrou que: “na data de hoje, juntamente com o policial civil Reginaldo, se dirigiu ao local dos fatos para verificar uma denúncia de nota falsa. Ao chegarem, foram atendidos pelo suspeito, que ao perceber que se tratava de polícia, correu em direção à residência, levando a mão à cintura e retirando um objeto, que foi atirado para a garagem. O suspeito, identificado como sendo Altair Moura Severo dos Santos, foi dominado e os policiais perceberam que o objeto anteriormente jogado era uma arma de fogo, que estava desmuniada. Ao abordá-lo, o depoente deu-lhe voz de prisão em flagrante, tendo o autuado sido algemado. Em seguida, ingressaram no imóvel, procedendo buscas no quarto de Altair, nada de irregular sendo encontrado. O autuado foi apresentado nesta delegacia, sendo a voz de prisão ratificada. Não conhecia Altair antes dos fatos, sendo que o genitor dele foi cientificado de sua prisão” (fls. 2).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial civil Reginaldo Aparecido Lasaro (fls. 3).

Às fls. 59-60, certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 5, fotografia de fls. 6 e laudo de exame de fls. 44/46.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido Christiano de Munhoz Rodrigues, policial civil. Receberam uma informação de que um cidadão estava disponibilizando para interessados notas falsas, assim como remédios usados para o golpe “boa noite, Cinderela”. Se não se engana, ele também anunciou a arma no Facebook. Fizeram contato por telefone para o réu e ele disse que sairia na rua. No contato, pediram para comprar a arma? Não se recorda do que foi dito. Quando ele saiu de casa, viu a polícia e jogou um objeto para dentro de casa. Abordaram o indivíduo e entraram na casa. Viram que o objeto era uma arma. Foi uma surpresa, pois achavam que ele ia apresentar notas falsas ou remédios. Ele não teve tempo de entrar. Ele arremessou o objeto. Os familiares apareceram e eles “entraram na casa para explicar o que estava acontecendo”. Fizeram busca na casa para buscar arma de fogo, munição e notas falsas, mas nada localizaram. Não apresentou documentação da arma. Quando ele arremessou o objeto, não pode ver que era arma. Pelo local que ele levou a mão e pelo barulho que fez, chegou à conclusão que era uma arma. Disse que a situação foi muito séria e poderiam ter disparado contra ele porque ele arremessou algo para dentro de casa. Perguntado, disse que recebeu a informação de um informante seu cujo nome não pode indicar. Foram, em menos de 15 minutos, para a rua onde o réu reside, ligaram para o número dele – fornecido pelo informante – e disseram que queriam um contato pessoal para ter um entendimento. Não indicou o que realmente disseram ao réu, mas sinalizaram que buscaram mostrar interesse em comprar algo de ilícito que ele vendia para atraí-lo. Não conhecia o réu.

b) Na sequência, foi ouvido o policial civil Reginaldo Aparecido Lasaro. Recebeu denúncia que uma pessoa anunciava em um site notas falsas, remédios esportivos e uma arma. Sabiam a rua e ligaram para o telefone que constava do site. Feito o contato, ele saiu de casa e ia em direção à viatura descaracterizada, deve ter percebido que era a polícia e jogou o objeto para dentro de casa. [Chegou a ver o site?] Não, a pessoa que passou a informação viu o site. Só foram checar a informação. Ele jogou a arma na garagem da residência de onde ele saiu para os atender. [Chegou a ver que era uma arma?] A maneira como ele jogou e de onde tirou o objeto o fez entender que era uma arma. A arma foi apreendida, era revólver desmuniado que o réu alegou ser de colecionador. A família saiu da casa, explicaram a prisão e entraram na casa. Buscaram e não encontraram nem nota falsa,

nem remédios. O réu disse que deixou a arma com ele para anunciar a venda, mas ele não indicou quem seria essa pessoa. Não conhecia o réu. [No contato telefônico, o que dito ao réu?] Que foram comprar as coisas que ele estava oferecendo.

c) Por fim, o réu Altair Moura Severo dos Santos foi interrogado. Realmente estava com a arma e ia vender para colecionador. Recebeu uma ligação, falaram para ele sair de casa, ele saiu com o objeto na cintura e se deparou com o carro prata parado na frente da sua casa. Viu 4 pessoas dentro do carro, assustou-se porque não era a pessoa que estava esperando. Correu par casa e jogou o objeto para dentro de casa. Ele estava rendido no chão, na frente de casa, e os policiais entraram na sua casa. Acharam a arma na garagem e nada mais. Ao receber a ligação, pensou que era a pessoa que ia comprar a arma. Não é verdade que tinha anunciado a arma em uma rede social. Na época, estava desempregado e trabalha com a venda de antiguidades. Essa arma é bem antiga, na época tinha bastante contato com colecionadores, e ia vender essa arma como antiguidade. Não autorizou a entrada dos policiais em sua casa. Os policiais não pediram documentação da arma antes de entrarem em sua casa. Os policiais não localizaram nada mais de ilícito em sua casa.

- DO FLAGRANTE PREPARADO

Segundo o relato do policial civil, ligaram para o réu e lhe disseram que queriam comprar o que ele estava oferecendo. A arma não foi anunciada em rede social ou em site – não há nos autos prova dessa alegação dos policiais. Uma pessoa foi indicada como a que desejava comprar uma arma e não a ofereceu para mais ninguém. Falou com essa pessoa e, quando os policiais lhe ligaram, pensou que era essa pessoa. Nesse caso, portanto, a polícia instigou a ocorrência do delito, atraindo Altair para fora de casa, a fim de flagrá-lo com algo ilícito – que nem sabiam o que era. Sendo o caso de flagrante preparado, é o caso de absolvição, nos termos da súmula 145 do STF.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE PROBATÓRIA

Conforme se infere dos autos, é incontestável que a apreensão de arma foi efetuada na residência do denunciado, sem qualquer comprovação de que o acusado franqueou a entrada no local.

Segundo os policiais civis, eles foram à residência do acusado para averiguar suposta denúncia de venda de “nota falsa” ou de remédios. De posse apenas de uma denúncia anônima, deslocaram-se até a residência de uma pessoa suspeita sem realizar qualquer outra diligência investigatória. Ali chegando, e sem mandado de busca e apreensão, adentraram a residência sem autorização do morador porque supostamente ele não reagiu bem à presença da polícia a sua porta. Ora, ninguém é obrigado a ser receptivo com a presença da polícia na porta da sua casa! Ademais, se 4 desconhecidos aparecem em frente a sua casa, uma pessoa normalmente se assusta. Assim como arremessou a arma, poderia, por exemplo, ter arremessado um aparelho celular, no receio de ser assaltado – tal como se vê hodiernamente nos noticiários. Correr, busca esconder o que tem de valor qualquer reação negativa a 4 pessoas desconhecidas que se passam por compradores para lhe abordar não é fundada razão para invadir uma residência.

Tem-se, por isso, que o ingresso na residência do denunciado deu-se em desconformidade com a garantia do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A esse propósito, deve-se frisar que, não obstante seja permitida a busca pessoal independentemente de mandado judicial (CPP, art. 244), a busca domiciliar somente poderá ser realizada quando o ingresso na residência seja legítimo, isto é, com “[...] o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” (CF, art. 5º, XI). Com efeito, nos termos do art. 241 do Código de Processo Penal, “Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado”. Todavia, ainda que tal dispositivo pareça autorizar a busca domiciliar sem a prévia expedição do mandado de busca e apreensão, é certo que não foi ele recepcionado pela atual Constituição Federal, cujo art. 5º, XI, estipula que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Assim, de acordo com Gustavo Badaró:

“O dispositivo é criticável. A CR [Constituição Federal] estabeleceu que a garantia da inviolabilidade do domicílio somente pode sofrer restrição mediante ordem judicial (art. 5º, XI). Assim, salvo hipótese de flagrante delito, mesmo que a busca seja realizada pela autoridade policial, será necessária a determinação judicial e, conseqüentemente, a expedição do mandado de busca (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 516).

Na mesma linha, Antonio Magalhães Gomes Filho esclarece que:

“Exige-se para a busca domiciliar, como visto, a expedição de um mandado judicial, uma vez que a Constituição garante a inviolabilidade da casa do indivíduo, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial (art. 5º, XI, CF). Pela redação do art. 241 do CPP, infere-se que a busca domiciliar poderia ser realizada pela própria autoridade policial ou mediante mandado por ela expedido. Mas essa regra não foi recepcionada pela Constituição de 1988, sendo de rigor a ordem judicial (BADARÓ, Gustavo Henrique; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias. Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 479).

E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte se posicionou no sentido de que é prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais ingressem no domicílio do acusado, desde que existam fundadas razões de prática de ilícito, configurando, assim, o flagrante de crime. Contudo, na hipótese, não ficaram demonstradas as fundadas suspeitas de que estaria sendo cometido um delito na residência.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1392367/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

Ademais, sobre o ponto, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, reconheceu que a busca domiciliar realizada sem a prévia expedição de mandado de busca e apreensão somente é legítima, não violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal, quando presentes “fundadas razões” que a legitimem:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que

havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

A tese foi fixada em sede de repercussão geral, tornando sua observância obrigatória pelos demais tribunais (CPC, art. 927, III, c. c/ art. 3º do CPP). Encampando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a simples fuga do imputado para o interior de sua residência não gera a fundada suspeita capaz de legitimar a busca domiciliar sem a prévia e indispensável expedição de mandado de busca e apreensão, violando, pois, o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. A decisão foi noticiada no seu Informativo n. 666:

No caso, as razões para o ingresso no imóvel teriam sido a natureza permanente do tráfico, a denúncia anônima e a fuga do investigado ao avistar a polícia. Em relação à tentativa de fuga do agente ao avistar policiais, deve-se salientar que, nos termos do entendimento da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância, por si só, não configura justa causa exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Deve-se frisar, ainda, que "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Neste ensejo, vale destacar que, em situação semelhante, a Sexta Turma desta Corte entendeu que, mesmo diante da conjugação desses dois fatores, não se estaria diante de justa causa e ressaltou a imprescindibilidade de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas (RHC 83.501/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 05/04/2018).

Desta feita, entende-se que, a partir da leitura do Tema 280/STF, resta mais adequado a este Colegiado seguir esse entendimento, no sentido da exigência de prévia investigação policial da veracidade das informações recebidas. Destaque-se que não se está a exigir diligências profundas, mas breve averiguação, como "campana" próxima à residência para verificar a movimentação na casa e outros elementos de informação que possam ratificar a notícia anônima (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Trata-se, aliás, de entendimento pacificado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado

em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

4. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.

5. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar a casa em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso na moradia alheia a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou no local de abrigo.

6. Na hipótese sob exame, verifica-se que o acusado supostamente empreendeu fuga para o interior de sua residência ao avistar a autoridade policial, que realizava diligência de rotina. A moldura fática descrita no acórdão combatido permite verificar que o único motivo que levou os policiais a ingressar no pátio do domicílio do investigado foi o fato de ele estar transitando em uma motocicleta, na posse de uma mochila vermelha, e haver entrado em sua morada quando percebeu a presença da autoridade policial.

7. Em nenhum momento foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado, externalizada em atos concretos. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanhas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior da residência (aliás, não há nem sequer menção a informes sobre a possível prática do crime de tráfico de drogas pelo autuado).

8. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial.

9. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas. Assim, vê-se que a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva foram viciadas.

10. Ordem concedida para absolver o réu (HC 381.619/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

E, ainda:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2. A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.

3. O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da

ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

5. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo art. 11.2, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe: "Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação." 6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda.

7. Se, por um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

8. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.

9. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo.

10. Se é verdade que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, num primeiro momento, parece exigir a emergência da situação para autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial - ao elencar hipóteses excepcionais como o flagrante delito, casos de desastre ou prestação de socorro -, também é certo que nem todo crime permanente denota essa emergência.

11. Na hipótese sob exame, o acusado estava em local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas, quando, ao avistar a guarnição de policiais, refugiou-se dentro de sua casa, sendo certo que, após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (18 pedras de crack). Havia, consoante se demonstrou, suspeitas vagas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente, do local em que ele estava no momento em que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e em virtude de seu comportamento de correr para sua residência, conduta que pode explicar-se por diversos motivos, não necessariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora de mercancia ilícita de drogas.

12. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem

determinação judicial.

13. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu na espécie - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de qualquer preocupação em documentar e tornar imune a dúvidas a voluntariedade do consentimento.

14. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada do domicílio do recorrido, de 18 pedras de crack -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.

15. Recurso especial não provido, para manter a absolvição do recorrido. (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017)

Partindo desses precedentes, parece imperioso concluir que a simples fuga para o interior da residência não configura a fundada suspeita capaz de autorizar o ingresso na residência de um suspeito.

Ademais, nem se alegue que o denunciado teria consentido com o ingresso. Ora, o suposto consentimento de alguém submetido à abordagem policial se mostra incapaz de autorizar o ingresso em sua residência. Isso porque é inquestionável que, diante da situação de vulnerabilidade em que se encontrava o acusado, não poderia ter expressado o consentimento de maneira legítima, sendo certo, ainda, que não foi informado de que não estava obrigado a colaborar com os policiais militares, tendo em vista que é titular do nemo tenetur se detegere (CF, art. 5º, LXIII; CADH, art. 8.2.g). Nesse sentido, já decidiu Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. NULIDADE DA APREENSÃO. PROVA REMANESCENTE. INSUFICIÊNCIA. I. Nulidade por violação de direito constitucional. Inexiste previsão legal de busca domiciliar mediante o mero e suposto consentimento do proprietário, já que a anuência, quando de fato há, é evidentemente dada sob constrangimento. Ingresso não autorizado judicialmente, quando as investigações poderiam facilmente ter conduzido à representação por mandado de busca e apreensão. Pela clara violação ao artigo 5º, IX, da Constituição Federal, deverá ser decretada nula a apreensão dos objetos na residência do réu, remanescendo apenas a apreensão decorrente da busca pessoal e as provas dela derivadas. II. Tráfico de Entorpecentes. Não há provas da atividade de traficância. A investigação procedida pela Polícia Civil conta apenas com fotografias em nada comprometedoras, pessoas não identificadas e imputações pouco detalhadas. Em juízo, nada consta além do depoimento dos policiais e da negativa do réu. Impositiva a absolvição. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO (Apelação-Crime, n. 70058172628, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 15-05-2014).

No mesmo sentido, leciona Aury Lopes Jr.:

"[...] a busca e apreensão em domicílio de imputado cautelarmente presto somente pode ser realizada com mandado judicial, pois é insuficiente o consentimento dado nessa situação, por força da intimidação ambiental ou situacional a que está submetido o agente. Acrescente-se a isso o fato de que o direito de silêncio (e de não produzir prova contra si mesmo) reforça a proteção do domicílio, estando todos eles à beira da ineficácia em caso de prisão do agente.

Ou seja, a situação fática criada por força da prisão e a absoluta submissão do imputado ao poder estatal diluem as condições de possibilidade de pleno exercício de seus direitos fundamentais, devendo, mais do que nunca, nesses casos, ser colocado em dúvida (senão invalidado) qualquer tipo de consentimento ou confissão [...]" (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 729-730).

Sendo assim, é inquestionável que houve violação ao domicílio do averiguado (CF, art. 5º, XI), de modo que a apreensão da arma é oriunda de uma ilicitude (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157) e, por isso, é imprestável para a formação do convencimento judicial. Sendo assim, impõe-se o seu desentranhamento dos autos (CPP, art. 157, caput).

E, por via de consequência, resta afastada a materialidade do delito imputado ao denunciado, diante da violação da referida garantia constitucional, motivo pelo a denúncia deve ser rejeitada, não havendo, pois, a justa causa (CPP, art. 395, III).

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Caso se entenda pela licitude da apreensão da arma, de rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a confissão deve ser reconhecida, ainda que seja apenas a informal.

No mais, ausentes agravantes e outras atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição de pena.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime aberto.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

No mais, o caso comporta a aplicação do art. 44 do CP, motivo pelo qual se requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:
Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ALTAIR MOURA SEVERO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado com incurso no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03, porque no dia 24 de setembro de 2020, às 16h, na rua Josefina Antônia Sarkis, nº 265, bairro Vila Industrial, nesta cidade e comarca, possuía um revólver calibre 38 SPL, de uso permitido, sem numeração, no interior da sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05, fotografia a fls. 06 e laudo de exame a fls. 44/46).

Segundo a denúncia, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos para "verificar uma denúncia de nota falsa". Ao chegarem, foram atendidos pelo réu que, ao perceber que eram policiais, "correu em direção à residência, levando a mão à cintura e retirando um objeto, que foi atirado para a garagem".

O réu foi dominado e os policiais perceberam que se tratava de um revólver desmuniado, o qual foi apreendido e periciado.

Instado, o réu alegou que: "não sabe se a arma está apta para efetuar disparo.

Nunca tentou utilizá-la. Não tem munição. Adquiriu-a fazendo "rolo/troca" com pessoa desconhecida. Pretendia revendê-la por 8 mil reais" (fls. 04).

A denúncia foi recebida (fls. 56), o réu citado (fls. 87) apresentando resposta escrita, na qual o réu se resguardou ao direito de lançar sua defesa ao término da instrução processual (fls. 90/92).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência virtual (fls. 93/94).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em debates orais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

A Defesa requereu a nulidade da prova, por causa da impossibilidade do flagrante que foi preparado.

Não há que se falar em flagrante preparado, na medida em que o crime é permanente e mesmo que o réu não oferecesse a arma ou não deixasse a residência naquele momento, estaria mesmo assim em flagrante e, a qualquer momento, poderia ter sido abordado fora da casa. Assim, em sendo a ação ilícita do réu preexistente à ação dos policiais, o flagrante não era preparado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANTER EM DEPÓSITO PARA VENDA MEDICAMENTO DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HIPÓTESE DE FLAGRANTE PROVOCADO NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O pleito absolutório está motivado na falta de liame subjetivo entre os agentes, sob o argumento de que a corré foi a única responsável por manter a medicação proscria em depósito na sua residência. No entanto, a instância de origem decidiu que ficou amplamente comprovada a unidade de desígnios entre os agentes, de forma que a revisão desse entendimento demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 2. Não prospera a arguida nulidade decorrente de flagrante preparado, uma vez que a condenação foi fundamentada em conduta anterior e pré-existente à ação policial que teria simulado uma compra e venda com o acusado. Imputou-se ao réu o fato de manter em depósito para venda o medicamento de procedência ignorada, e o Tribunal de origem ressaltou que as fontes de prova foram independentes e desvinculadas da situação que ensejou a prisão em flagrante. 3. Os pedidos subsidiários - participação de menor importância;

aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e aplicação da pena de multa nos moldes do preceito secundário do art. 273 do Código Penal - não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, que sobre elas não emitiu expresso juízo de valor, motivo pelo qual não podem ser analisadas, ante o que preceitua a Súmula n. 211/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1877509/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1954924/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

A Defesa também arguiu a nulidade da prova, em razão da invasão de domicílio

Em recurso extraordinário, assim se manifestaram os Ministros da Corte Suprema:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não